

1500397-68.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247919/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 27333061 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2247919 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER PEREZ SOLER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500397-68.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247919/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 27333061 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2247919 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER PEREZ SOLER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

VAGNER PEREZ SOLER está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 138), o réu apresentou defesa (fls. 142/150).

A denúncia foi recebida em 4 de novembro de 2022 (fls. 152/153) e o réu foi citado (fls. 229).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 224). A defesa arguiu a quebra da cadeia de custódia e, no mérito, requereu a absolvição, além de tecer considerações acerca da dosimetria da pena (fls. 232/254).

É o relatório.
DECIDO.

De saída, afasto a preliminar arguida pela defesa, pois inexistente a quebra da cadeia de custódia aventada, ante a ausência de comprovação de não preservação dos materiais apreendidos.

As porções de entorpecentes foram propriamente acondicionadas em embalagens adequadas, lacradas e entregues à perícia para análise, não se observando elemento concreto a suscitar dúvida na confiabilidade das provas produzidas, pois o erro de digitação no número do lacre foi sanado pelo laudo pericial complementar acostado às fls. 91/92.

Não é demais observar, ainda, que a descrição do objeto da apreensão é a mesma (46 porções de substância em pó de cor branca acondicionada em tubos plásticos azuis, do tipo eppendorfs com peso de 38,4g) e, ainda, corresponde à fotografia do objeto apreendido e respectivo peso (fl. 37).

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/5), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), fotografias (fls. 37/38), laudos periciais (fls. 93/98, 99/101 e 209/211), além da prova oral.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e aduziu, em suma, que está sendo falsamente incriminado. Disse que estava sentado na calçada quando os policiais chegaram perguntando pela droga. Após a abordagem, eles liberaram Fernando (que estava perto da porteira) e o levaram até um pasto, onde o agrediram. Negou ter tentado fugir ou resistido à prisão e aduziu que os policiais procuraram no mato e encontraram droga, mas não sabe onde, pois estava de costas. Após a abordagem, os policiais telefonaram para "Luan Almeida" e pediram para que "Guimarães" fosse avisado sobre sua prisão. Foi torturado pelos policiais na delegacia e, por isso, afirmou que vendia drogas. Relatou que, no passado, envolveu-se em uma briga com policiais depois disso sua vida "virou um inferno". Eles costumam aplicar multas indevidas em todos os veículos pertencentes aos seus familiares. Tinha começado a trabalhar cerca de três dias antes de ser preso.

O policial militar André relatou ter recebido denúncias de que o réu havia voltado a vender drogas após ser colocado em liberdade, o que ensejou patrulhamento no bairro onde ele reside. A viatura circulava pela rua Salma Simão Azer e virou a rua Orlando Bertoluci, momento em que avistou o réu parado ao lado de um poste. Ele começou a caminhar a passos largos em direção a um terreno e dispensou uma garrafa verde no chão. Assim, saiu da viatura e tentou abordá-lo, ao que ele reagiu, mas foi contido. Em revista, encontrou cerca de R\$300,00 com o acusado. Dentro da garrafa estavam os eppendorfs de cocaína apreendidos. Informalmente, o réu admitiu estar comercializando entorpecentes no local.

O policial militar Audrin confirmou, em linhas gerais, o depoimento de seu colega e acrescentou que a equipe empreendeu buscas nos arredores, mas nada mais de ilícito foi encontrado.

Jéssica, esposa do réu, narrou que ambos estavam na casa de seu cunhado, quando o acusado saiu para atender a um chamado de um amigo. Logo após, saiu da casa também e viu seu marido sendo abordado pelos policiais. Na sequência, os policiais, que nada tinham encontrado até então, levaram seu marido até um pasto nas proximidades.

A testemunha Fernando disse que estava perto de um mato com seu cachorro, quando foi abordado juntamente com o réu. Ele foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. Após, ele foi levado a um mato e soube que acharam drogas no local. Não viu o acusado arremessando nenhum objeto e acredita que ele nem teve tempo para isso, pois os policiais viraram a esquina correndo. A esposa de Vagner estava sentada na calçada junto com ele antes da abordagem.

Pois bem. A despeito da negativa do réu, o crime que lhe foi imputado restou seguramente comprovado pelas provas produzidas.

Os policiais apresentaram narrativas harmônicas a respeito da dispensa do recipiente com drogas pelo acusado e não há nos autos elementos concretos capaz de afastar a credibilidade de tais relatos, até porque o acusado mencionou que sequer os conhecia, a despeito da alegação de ser perseguido por outros policiais com os quais teria se desentendido no passado.

Nesse sentido, vale conferir:

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

As testemunhas arroladas pela defesa apresentaram versões diferentes quanto à dinâmica dos fatos, pois a esposa do réu disse que estava dentro de casa quando os policiais chegaram, enquanto Fernando mencionou que ela estava com o acusado na calçada antes da abordagem.

Fernando ainda disse que Vagner não teria arremessado qualquer objeto, todavia posteriormente informou que estava perto de uma porteira no momento da chegada da viatura. E, pelo que se verifica do vídeo cujo link foi acostado pela defesa na pg. 150, referida porteira fica relativamente distante do local onde o objeto estava.

O acusado mencionou ter sido enforcado e agredido, o que não corresponde ao laudo pericial acostado às fls. 57/58, que foi realizado após a prisão e antes da realização de audiência de custódia, e atesta a ausência de lesões.

Ele também alegou ter sido torturado na delegacia de polícia, o que indicaria verdadeiro conluio entre policiais civis e militares (além do perito) para falsa incriminação do acusado, alegação inverossímil, até porque desprovida de motivação.

Nesta toada, considerando a dinâmica da abordagem, a dispensa de considerável quantidade de drogas pelo acusado e ausência de comprovação da origem lícita do dinheiro apreendido, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito narrado na denúncia restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, não verifico motivos aptos a ensejar a oscilação da pena-base, que fixo no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 122/123 – Proc. 1500418-30.2020.8.26.0302). Assim, aumento a pena de 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Inaplicável o benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente.

Em virtude da reincidência, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, CP.

A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal, à mingua de elementos que denotem condição financeira que permita a majoração.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a

pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal - art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, CPP poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu VAGNER PEREZ SOLER, qualificado nos autos, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade. Preso durante o curso do processo, com maior razão deverá permanecer custodiado, tendo em vista que continuam presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão cautelar, notadamente a necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do valor apreendido. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA